

1500598-47.2019.8.26.0022
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
Comarca: Amparo
Foro: Foro de Amparo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 28/04/2022
... 29/06/2020) [grifamos]

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Amparo
Foro de Amparo
2ª Vara
Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500598-47.2019.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500598-47.2019.8.26.0022
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -
2083933/2019 - DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL, 4286123 - DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL,
87/19/114 - DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL, 104/19/114 - DEL.POL.MONTE ALEGRE DO SUL
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
ADILSON PINHEIRO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Vistos.

Os réus ADILSON PINHEIRO e CARLOS ROBERTO JESUS ZOCA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal (fls. 204/206).

Consta da denúncia que, no dia 02 de março de 2019, por volta das 04h00, na Rua Firenze, Centro, na cidade de Monte Alegre do Sul/SP, ADILSON PINHEIRO e CARLOS ROBERTO JESUS ZOCA, junto com Anderson Leme Oliva Candido e Rogerio Augusto de Campos, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraíram, para si ou para outrem, 02 (duas) bombas de água, pertencentes à vítima Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul/SP.

Os acusados foram ouvidos perante a autoridade policial (fls. 44/45 e 58).

Boletins de ocorrência às fls. 02/03 e 14/18.

Auto de exibição e apreensão às fls. 19/21.

Relatório do Inquérito Policial às fls. 135/138.

A denúncia foi recebida em 22/05/2020 (fls. 207/208).

Os acusados foram citados (fls. 256 e 258) e apresentaram suas respostas à acusação às fls. 261/264 e 269/270.

Houve a confirmação do recebimento da denúncia (fls. 275/276).

Audiência virtual de instrução e debates orais gravados em sistema audiovisual, realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, atendendo ao disposto nos comunicados CGJ nº. 284/2020 e 317/2020.

Alegações finais da Acusação às fls. 346/348 pleiteando, em síntese, a condenação dos réus nos termos da denúncia e fixação de regime inicial fechado (fls. 394).

Sobreveio notícia de óbito do acusado Adilson (fls. 349), razão pela qual a sentença de fls. 385 julgou extinta a sua punibilidade.

Alegações finais da Defesa de Carlos às fls. 351/356 e 401/406 pleiteando, em síntese, a absolvição do réu por ausência de provas.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A imputação sob análise é assim definida no Código Penal, mais precisamente em seu Título II, que trata dos crimes contra o patrimônio:

"Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheiamóvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas. "

Pois bem, vejamos a prova oral colhida nos autos.

Em Delegacia, o guarda municipal MARCELO NERY (fls. 97/98) contou "QUE na data dos fatos, está em conjunto com seu parceiro Bruno realizando ronda pela cidade de Amparo, quando recebeu ligação do investigador de polícia de Monte Alegre do Sul, informando que uma bomba de água, furtada da cidade de Monte Alegre do Sul, havia sido encontrada em uma casa em Amparo; QUE, de posse dessa informação, em conjunto com a Polícia Civil de Monte Alegre do Sul, se deslocaram até a Rua El Salvador, 266, Jd. América, Amparo, onde localizaram o suspeito Adilson, que após ser indagado acerca dos objetos subtraídos, informou que parte dos mesmos, isto é, duas bombas e um motor, estavam em sua oficina de tapeçaria, com endereço no local dos fatos, razão pela qual as equipes para lá se deslocaram, onde foram localizadas, além das bombas e motor, algumas ferramentas, também pertencentes à municipalidade,

igualmente subtraídas quando dos fatos. Ato contínuo, tudo e todos foram encaminhados a essa Delegacia para a realização dos atos pertinentes. Ocorre que, durante o desenvolvimento dos trabalhos, se obteve a informação que o motor faltante estava na residência de Anderson Leme Oliva Candido, razão pela qual foi determinado pelo Delegado diligências no referido endereço, a saber, Rua Humberto Afonso Cozoli, 93, Jardim Paulistano, Amparo/SP, onde localizaram Anderson que, ao ser indagado acerca do tal motor, indicou o local onde o mesmo estava, ou seja, na garagem de sua residência. Em seguida tudo e todos foram conduzidos a essa Delegacia. Os objetos recuperados (duas bombas de água, dois motores e diversas ferramentas) foram devidamente apreendidos e entregues a quem de direito.".

Também em Delegacia, o guarda municipal BRUNO DO CARMO SILVEIRA (fls. 95/96) afirmou "QUE na data dos fatos, está em conjunto com seu parceiro Marcelo realizando ronda pela cidade de Amparo, quando seu parceiro recebeu ligação do investigador de polícia de Monte Alegre do Sul, informando que uma bomba de água, furtada da cidade de Monte Alegre do Sul, havia sido encontrada em uma casa em Amparo; QUE, de posse dessa informação, em conjunto com a Polícia Civil de Monte Alegre do Sul, se deslocaram até a Rua El Salvador, 266, Jd. América, Amparo, onde localizaram o suspeito Adilson, que após ser indagado acerca dos objetos subtraídos, informou que parte dos mesmos, isto é, duas bombas e um motor, estavam em sua oficina de tapeçaria, com endereço no local dos fatos, razão pela qual as equipes para lá se deslocaram, onde foram localizadas, além das bombas e motor, algumas ferramentas, também pertencentes à municipalidade, igualmente subtraídas quando dos fatos. Ato contínuo, tudo e todos foram encaminhados a essa Delegacia para a realização dos atos pertinentes. Ocorre que, durante o desenvolvimento dos trabalhos, se obteve a informação que o motor faltante estava na residência de Anderson Leme Oliva Candido, razão pela qual foi determinado pelo Delegado diligências no referido endereço, a saber, Rua Humberto Afonso Cozoli, 93, Jardim Paulistano, Amparo/SP, onde localizaram Anderson que, ao ser indagado acerca do tal motor, indicou o local onde o mesmo estava, ou seja, na garagem de sua residência. Em seguida tudo e todos foram conduzidos a essa Delegacia. Os objetos recuperados (duas bombas de água, dois motores e diversas ferramentas) foram devidamente apreendidos e entregues a quem de direito.".

Perante a autoridade policial, o acusado negou qualquer envolvimento com os fatos narrados, afirmando desconhecer os demais supostos envolvidos (fl. 58).

Em juízo, o representante da vítima Adilson José Crippa contou que, a respeito da subtração de duas bombas de água da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul, chegou para trabalhar, ligou a estação, percebeu que não ligava, foi até o local e viu que as bombas não estavam, chamou o Prefeito, que acionou a polícia. No dia seguinte, as bombas funcionaram normalmente até 22h ou 23h. Acredita que o furto se deu na madrugada. As bombas foram recuperadas cerca de 15 a 20 dias depois. Não sabe com quem estavam. Não sabe se Rogerio participou do furto. Quando foi à delegacia de polícia, disse que estavam comentando que havia sido Rogerio quem havia dado a dica, mas não ouviu nada da boca dele, nem dos envolvidos. A Prefeitura Municipal teve o prejuízo de montar e remontar a bomba. Três bairros tiveram falta de água, o que representa mais ou menos 40% da cidade. Foi sábado e domingo. As bombas são pesadas. Seria difícil uma pessoa tirar sozinha. Qualquer pessoa poderia tirá-las de lá. O local não tem câmara de segurança. As bombas poderiam ser colocadas em um único veículo. Acredita que caberiam em um Fiat Uno.

A testemunha de acusação Marcelo Nery, guarda municipal, devidamente compromissado, disse que estava em serviço e teve conhecimento de um furto ocorrido há um tempo. Em contato com a polícia civil de Monte Alegre, souberam que parte das bombas estaria no trabalho do réu Adilson. Lá, foram localizadas as bombas e algumas ferramentas que possivelmente teriam sido utilizadas. Ainda em diligência com a Polícia Civil, receberam informação de que a outra bomba estava na residência do Anderson, até onde foram e encontraram. Conduziram então Adilson e Anderson. Disse

que não houve confissão informal. Não se recorda do que falaram para ele. Não participou de investigações sobre o fato. No dia em que foi buscar Zoca, ele foi abordado em deslocamento no centro da cidade de Amparo. Contaram-lhe que havia filmagens, mas não viu. Zoca teria sido abordado porque a Polícia Civil disse que ele tinha participação. Afirmou que o Delegado queria ouvir a versão do Zoca.

A testemunha de defesa Bruno do Carmo Silveira Brasileiro, guarda municipal, devidamente compromissado, contou que trabalha em Amparo e tiveram informações anônimas de que as bombas estariam escondidas em Amparo. Entraram em contato com a polícia civil de Monte Alegre do Sul e foram em diligências. Com Adilson, encontraram uma das bombas. Em relação a Zoca, na Delegacia, obtiveram informações de que ele teria participação. Deslocaram-se para Amparo, encontraram-no em uma praça e o conduziram para ser ouvido pelo Delegado. Conversou com Roberto investigador. Não chegou a ver nenhuma gravação. Sobre Adilson, disse que a informação anônima veio pelo 153 e que é comum a atuação da guarda municipal de Amparo em apuração de denúncias, inclusive sem situação de flagrante. Sobre Zoca, disse que a informação de sua participação delitiva veio da Polícia Civil. Disse que só a guarda municipal foi até Zoca, sem acompanhamento da polícia civil. Disse que Zoca foi à Delegacia de livre e espontânea vontade.

A testemunha de defesa Roberto Baldon Varga, policial civil, devidamente compromissado, contou que não sabe se voltaram informações após seu relatório, que seu serviço acabou no relatório. Conversou com Adilson quando entraram em sua tapeçaria e Adilson teria falado o nome dos demais. Não tem conhecimento sobre os demais, pois foi Adilson quem falou sobre eles na Delegacia. Conversou com os guardas, mas não se lembra de conversar com Bruno. Foi o Delegado quem determinou a ida da guarda municipal para buscar Zoca. Acredita que todos foram liberados no mesmo dia. Disse que recebeu denúncia de que Adilson teria a bomba. Adilson franqueou a entrada e depois acompanhou os policiais e guardas na Delegacia. Não conseguiu ver placas de carros. Não se recorda de confissão informal de Anderson. A primeira diligência foi no endereço de Adilson em decorrência de ligação que fizeram na Delegacia. Lá no endereço, Adilson permitiu o ingresso dos policiais e guardas. Dessa diligência, com a ida de Adilson à Delegacia, obtiveram o nome dos demais participantes no delito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

Da jurisprudência, trago à colação: não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese" (STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25/05/2010).

Interrogado em juízo, o réu Carlos Roberto Jesus Zoca contou que são falsos os fatos da denúncia e que não participou. Disse que estava com um conhecido seu de nome Randal. Disse que estava na lanchonete do Fernando em Amparo e que lá ficou até por volta das 5 horas da manhã, pois era sábado de carnaval. Não conhece os demais acusados, inclusive por nome ou vídeo. Tem um gol prata. Chegou à Delegacia preso, algemado e com forte pressão para confessar. Foi preso, algemado e conduzido numa viatura da guarda municipal de Amparo. Não estava acompanhado de advogado. Não

viu Adilson, nem o outro indivíduo. Contou que, após impetrar um habeas corpus por constrangimento ilegal contra as polícias civil e militar, começou a sofrer forte pressão dos policiais de Amparo. Disse que o Delegado lhe disse para confessar, pois já sabiam que era ele. Ficou até altas horas lá. Não confessou em Delegacia. Atribui a acusação à perseguição sofrida. Não lhe foi mostrada nenhuma gravação no dia dos fatos.

Interrogado em juízo, Adilson Pinheiro disse que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros. Viu Zoca uma vez na cadeia em 2004 e nunca mais tiveram contato. Viram-se duas semanas antes do ocorrido. Disse que não foi algo planejado. Nunca tiveram quadrilha. Disse que não passou o nome do Zoca e do Anderson para a polícia. Disse que a polícia civil de Monte Alegre e os guardas municipais de Amparo apareceram na sua casa, que também é uma tapeçaria. Disseram-lhe que ele poderia não permitir, mas que seria fácil conseguir uma ordem judicial para entrar. Então, concedeu a entrada e encontraram a bomba. Sentiu temor. Sentiu-se obrigado a permitir a entrada. Narrou sobre a dinâmica do furto, a subtração das bombas, que foram colocadas em carros e trazidas para Amparo. Utilizaram os veículos Gol e Uno, dirigidos por Anderson e Zoca. Confirmou que Zoca era quem estava na audiência virtual. O furto ocorreu de noite. Não conhece, nem viu Rogério Augusto. Esteve acompanhado de advogado em Delegacia. Não o conhecia, foi indicado por um policial, que ligou para ele.

No caso em tela, a despeito da discussão quanto a participação direta do acusado no delito, o réu deve ser absolvido em razão da ilicitude da prova, que por sua vez decorreu da ilegalidade da atuação da guarda civil municipal.

Explico.

Nos termos do art. 144, caput e incisos, da Constituição Federal, “a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares”. No § 8º, fica estabelecida a possibilidade de criação das Guardas Municipais, com os limites de sua atuação: § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Constata-se, assim, que a Constituição Federal não atribuiu à Guarda Municipal atividades ostensivas típicas de Polícia Militar ou investigativas de Polícia Civil, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, o que já foi reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo em Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 13.866/06 que fixava, dentre as atribuições da guarda municipal da capital, “exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos”.

Confira-se a ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana – Art. 147 da Constituição Estadual – Proteção dos bens, serviços e instalações municipais – Matéria debatida é atinente à segurança pública – Preservação da ordem pública – Competência das polícias, no âmbito do Estado – Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais – Extrapolação dos limites constitucionais – Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. (ADI nº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 10/12/2008). [grifamos]

Pelo mesmo fundamento, o Colendo Órgão Especial do TJ-SP vem declarando inconstitucionais leis municipais que alteram a denominação da guarda municipal

para Polícia Municipal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei 5.626, de 16 de abril de 2018, do Município de Valinhos, que assegurou à Guarda Municipal a identificação como 'Polícia Municipal de Valinhos' - Alegação do Prefeito, autor da ação, de usurpação da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar matéria sobre a organização dos serviços públicos municipais, violando a separação os poderes - VÍCIO DE INICIATIVA - Projeto apresentado por parlamentar direcionado à nova designação da Guarda Municipal - Matéria claramente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação dos artigos 5º, 24, § 2º, item 4, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144 - Incidência, ainda, do preceito do artigo 147 da Carta Bandeirante, que reproduz o texto do artigo 144, § 8º, da CF/88, que estabelece que a guarda municipal é força de natureza civil destinada à proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União - Inconstitucionalidade das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil - Não violação, por outro lado, dos preceitos orçamentários, segundo Tema 917, em repercussão Geral, no S.T.F. - Ação julgada procedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286983-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020) [grifamos]

Noutra oportunidade, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a sentença de piso foi confirmada pela 1ª Câmara de Direito Público no sentido de reconhecer a obrigação de não fazer, condenando-se a Guarda Municipal de Araçatuba a abster-se de efetuar atividades próprias de Polícia Judiciária (inquirição de suspeitos, busca pessoal e apreensão de objetos):

APELAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -OBRIGAÇÃO DE FAZER - FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - Incidente decorrente da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 1010780-61.2015.8.26.0032, instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de Araçatuba - Reconhecimento de obrigação de não fazer, condenando-se a Guarda Municipal de Araçatuba a abster-se de efetuar atividades próprias de Polícia Judiciária (inquirição de suspeitos, busca pessoal e apreensão de objetos) - Reiterada recalcitrância no cumprimento da decisão - Anterior aplicação de astreintes, no montante de R\$ 10.000,00, R\$ 20.000,00 e 25.000,00 que se mostraram insuficientes - Fxação de nova multa coercitiva no valor de R\$ 30.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade da medida - Pronunciamento judicial mantido - Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 0008351-65.2020.8.26.0032; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 22/06/2021) [grifamos]

É essa também a lição da doutrina constitucionalista.

José Afonso da Silva (Comentário Contextual à Constituição, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638/639) assevera que: "Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de

polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, §4º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais." [grifamos]

Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, v. 5, p. 246) observa que "A Constituição de 1988 atribuiu às Guardas Municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º), não as fazendo auxiliares da Polícia Militar nem lhes conferindo função repressiva dos crimes".

Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini (Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini, Guarda Municipal - Criação e Implantação - Constituição Federal - Constituição Estadual - Lei Orgânica do Município, in Boletim de Direito Municipal, ano IV, nº 3, pág. 203) também destacam que às guardas municipais "não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil".

Também nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova. 3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP. (STJ - HC: 561329 SP 2020/0033756-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020) [grifamos]

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal. (RHC 142.588/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) [grifamos]

No voto-vista do primeiro julgado acima, o Ministro Saldanha Palheiro ainda destacou: "O mero indício de que o agente encontra-se em estado de 'nervosismo' não é suficiente para autorizar a busca pessoal, porquanto não pode ser considerado fundada suspeita de que a pessoa esteja praticando algum delito ou em posse de seus produtos. Portanto, entendendo descabida a atuação da guarda municipal em razão de suas atribuições não abarcarem o policiamento ostensivo e a realização de busca pessoal."

No segundo julgado acima mencionado, o Ministro Relator consignou que, em

consonância com a jurisprudência do próprio STJ, "inexiste qualquer óbice à realização de prisão, em situação de flagrância, por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, e somente por isso, em ilicitude das provas daí decorrentes". Nada obstante, entendeu o Relator que, "quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º. do artigo 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, o fato de um dos ocupantes ter saído do veículo ao avistar a viatura, aparentando nervosismo, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal e veicular ocorrida posteriormente". Assim, acrescentou o Ministro, "se não amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e, nos termos do artigo 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de constatação da droga, afastando-se, conseqüentemente, a prova de existência do fato".

Há também julgados criminais do E. TJ-SP sobre o tema, por exemplo:

Revisão Criminal. Roubo qualificado. Abordagem do réu por Guardas Municipais. Existência de prova a contaminar a ação penal. Impossibilidade de realização pela Guarda Municipal de atos privativos das Polícias Judiciária e Militar. Pretensão absolutória acolhida Apelo provido" (TJ/SP - Revisão Criminal nº 0162917-15.2013.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 04/04/14) [grifamos]

Tráfico de Drogas - Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500144-13.2020.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 4ª Vara; Data do Julgamento: 21/05/2021; Data de Registro: 21/05/2021) [grifamos]

RECURSO DE APELAÇÃO. Interposição pela parte ré, ora recorrente. Sentença condenatória. Prova Ilícita. Revista pessoal realizada por guarda municipal sem situação de flagrância prévia e visível. Ausência de atribuição da guarda municipal para atividade de polícia investigativa ou ostensiva. Atuação das guardas municipais que se destina à proteção dos bens, serviços e instalações municipais a teor do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal (CF/88). Entendimento consolidado no Órgão Especial do E. TJ-SP, bem como no E. STJ e na doutrina. Ausência, ademais, no caso, de fundada suspeita de que a pessoa abordada ocultasse objetos ilícitos consigo, requisito legal imprescindível para a busca pessoal nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP). Revista pessoal baseada exclusivamente no fato de a condutora da moto estar transitando na via de maneira irregular. Possibilidade de lavratura de auto de infração de trânsito se houver previsão em lei municipal, mas não de ordem de parada e abordagem. Prova ilícita de materialidade que conduz, por conseguinte, à absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (CPP). RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1557729-07.2018.8.26.0477; Relator (a): Orlando Gonçalves de Castro Neto; Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal - Santos; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Receptação - averiguação por GCMS iniciada por delação anônima - ausência de flagrante - não incidência do art. 301 do CPP - exorbitância dos poderes atribuídos

no art. 144, § 8º, da CF – decisão judicial em ACP vedando atividade investigativa por GCMS em Birigui - prova ilícita – absolvição (TJSP; Apelação Criminal 0000358-72.2018.8.26.0603; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020) [grifamos]

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 654, §2º, CPP – ILEGALIDADE CONSTATADA DE PLANO – PROVA ILÍCITA – REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL SEM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA PRÉVIA E VISÍVEL – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL PARA ATIVIDADE DE POLÍCIA INVESTIGATIVA OU OSTENSIVA – ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS QUE SE DESTINA À PROTEÇÃO DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS – ART. 144, §8º, CF – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP, BEM COMO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NA DOCTRINA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE OCULTASSE OBJETOS ILÍCITOS CONSIGO – REQUISITO LEGAL PARA BUSCA PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 244, CPP – REVISTA PESSOAL BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO FATO DE QUE O RÉU ESTAVA TRANSITANDO EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA NA VIA COM SUA MOTOCICLETA – INSUFICIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJSP; Apelação Criminal 1501823-63.2020.8.26.0347; Relator (a): Leonardo Issa Halah; Órgão Julgador: Turma Criminal; Foro de Matão - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data de Registro: 14/06/2021) [grifamos]

No penúltimo acórdão acima citado, o Desembargador Vico Mañas afirmou que "Não se ignora que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo de Penal, qualquer do povo está autorizado a realizar prisão em flagrante. Diversa, todavia, a situação em exame. Não houve flagrante puro e simples. Tudo começou com informação de presença de carro subtraído em terreno recebida pelos GCMS". O Magistrado lembrou que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Assim, afirmou que atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem função das polícias civil e militar. Então, concluiu que, "Nesse cenário, forçoso reconhecer que, jungidos à legalidade estrita, que só permite ao agente público fazer o que estiver expressamente previsto em lei, os guardas municipais não estavam autorizados a proceder à averiguação da denúncia recebida, não configurado flagrante de pronto, até porque desconheciam o responsável pelo depósito".

Nem se alegue a edição da Lei nº 13.022/14 para justificar e legitimar a atuação da guarda municipal como se polícia fosse, pois tal ato legislativo foi editado para regulamentar o artigo 144, § 8º, da CF e, assim, por regra fundamental de hermenêutica constitucional, as normas infraconstitucionais regulamentares não podem alargar o âmbito de competência claramente definido pela norma constitucional, que não concedeu à guarda municipal qualquer atuação em matéria de segurança pública.

Para além da limitação do artigo 144, 8º, CF, acima mencionada, mais um argumento reforça a impossibilidade de que as guardas municipais realizem atividades típicas das polícias. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, em contrapartida ao uso da força pública que exercem, respondem perante a atividade correcional externa do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual), estando ambas submissas ao controle administrativo que tem na pessoa do Governador do Estado sua autoridade máxima.

Já a Guarda Civil Municipal – sem prejuízo da importância de seus préstimos constitucionais ou da honradez de seus membros, é claro – não está sujeita a controle correcional externo algum do Poder Judiciário ou do Ministério Público, estando sob controle administrativo apenas do poder político constituído na própria

localidade.

Por certo, não se desconhece que, nos termos do art. 301, CPP, “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o que permite que as guardas municipais façam prisões em flagrante, conforme admitido pela jurisprudência.

Tal dispositivo, todavia, diz respeito aos flagrantes visíveis e evidentes de plano, como, por exemplo, a situação em que um transeunte vê um assalto acontecendo, desarma o assaltante e o prende em flagrante delito, ou então quando alguém vê uma pessoa explicitamente vendendo drogas e lhe dá voz de prisão em flagrante. Completamente diferente, por outro lado, é a hipótese em que a situação de flagrante só é descoberta após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, já que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar e revistar seus semelhantes, valendo lembrar ainda que a busca pessoal exige também a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244, Código de Processo Penal - CPP).

No caso dos autos, os guardas municipais da cidade de Amparo, após receberem informações anônimas da localização das bombas furtadas na cidade de Monte Alegre do Sul, entraram em contato com a Polícia Civil de Monte Alegre do Sul e foram em diligência até a casa de Adilson, onde localizaram uma das bombas. Conforme afirmado por Adilson, ele foi pressionado a permitir a entrada da polícia civil de Monte Alegre e dos guardas municipais de Amparo em sua residência.

Em relação ao acusado Carlos, os guardas municipais de Amparo obtiveram informação na Delegacia de Monte Alegre do Sul de seu suposto envolvimento, razão pela qual foram até Amparo, encontraram-no em uma praça e o conduziram para ser ouvido pelo Delegado de Monte Alegre do Sul. A condução de Carlos foi realizada somente pela guarda municipal de município distinto, sem o acompanhamento da Polícia Civil.

Desta forma, observa-se que a entrada na residência de Adilson foi realizada sem que houvesse qualquer situação clara e prévia de flagrante delito que a justificasse nos termos do artigo 301 do CPP. Igualmente, a condução do acusado Carlos, o qual não se enquadrava nas hipóteses de flagrante delito ou ainda fundada suspeita de que o acusado ocultasse objetos ilícitos (art. 244, CPP).

Isso porque, conforme narrativa dos próprios guardas municipais nestes autos, em atuação que acima já reconhecemos ilegal, após tomarem conhecimento de um furto ocorrida na cidade vizinha em que atuam, resolveram agir em atividade investigativa, indo até a residência de Adilson e, após, juntamente com a polícia civil, foram em diligência até a residência de Anderson, havendo novamente ilegalidade.

Como se não bastasse, após receberem informações da Polícia Civil de Monte Alegre do Sul - e, essencial que se frise, de outro Município daquele em que atuam os guardas municipais - de suposta participação do réu Carlos, os guardas municipais foram sozinhos até Amparo, encontraram o réu em uma praça e o conduziram para ser ouvido pelo Delegado no outro município (Monte Alegre do Sul).

Ora, não só não havia estado de flagrância, como inexistia qualquer indicativo de que o réu estivesse praticando crime que autorizasse qualquer um do povo a abordá-lo e muito menos realizar a sua condução.

Nota-se que os guardas municipais realizaram a condução do réu Carlos sem ao menos verificarem as provas que supostamente possuíam os policiais civis de Monte Alegre do Sul e, nitidamente, fora de qualquer das hipóteses de flagrante delito.

Ressalto, porque essencialmente importante: a guarda municipal de Amparo, após informações obtidas na delegacia de outro município (Monte Alegre do Sul), deslocou-se até Amparo e, sozinha, realizou a condução do réu Carlos até a delegacia do outro município, realizando atividade investigativa, típica da polícia judiciária.

Ademais, na própria investigação que indicou a suposta participação do réu Carlos, decorrente das diligências realizadas nas residências de Adilson e Anderson, houve a ilegal participação da guarda municipal de Amparo, que desempenhou, novamente, atividade investigativa típica de polícia judiciária.

Frise-se que os guardas municipais atuaram na mais legítima boa-fé. Isso porque, indagados em audiência, confirmaram que atuam como polícia ostensiva, com caráter muito semelhante à polícia militar, afirmando ser comum a atuação da guarda municipal da Amparo em denúncias, inclusive sem situação de flagrante.

Registre-se, porque deveras importante, que não se pretende aqui imputar má-fé aos honrosos agentes municipais, de forma alguma. Certamente, estavam de boa-fé e acreditavam que poderiam agir como agiram, tanto que descreveram o ocorrido tal como aconteceu em seus depoimentos. Todavia, tal boa-fé não afasta a ilicitude da ação, servindo apenas para isentá-los de responsabilidade pelo ocorrido, sendo certo que não cabe à guarda municipal assumir o papel de polícia ostensiva e ainda investigativa, deslocando-se até a residência de suspeitos ou realizando a sua condução, já que isso em nada se relaciona com a proteção dos bens do Município, seus serviços e instalações.

Portanto, pelo contexto fático delineado nos autos em análise, em que pese eventual boa-fé da guarda municipal, não havia elementos concretos que justificassem o ingresso na residência de Adilson e, posteriormente, na de Anderson.

Eis a razão pela qual, dado que a guarda municipal não poderia, nas circunstâncias do caso em tela, ter realizado a atividade investigativa, de maneira que as provas obtidas por meio da medida são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram (por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada – art. 157, §1º, CPP), o que impõe a absolvição do réu por ausência de provas acerca da autoria do delito de furto.

Não desconheço que, aos olhos de um leigo, soe desarrazoado se permitir a absolvição de alguém que talvez fosse "materialmente culpado" pelo fato de a prova contra ele ter sido produzida por meios ilícitos, porque, para o senso comum, os fins justificam os meios. Ocorre que, no atual estado civilizatório do Estado Democrático de Direito, a atividade estatal encontra-se balizada por regras de atuação claras e previamente estabelecidas, as quais devem ser rigidamente obedecidas.

Se a Constituição Federal estabelece competências e exige requisitos para a abordagem e revista pessoal dos indivíduos, é porque entende que a intimidade e a privacidade dos indivíduos são valores fundamentais a serem preservados, ainda que isso possa, em alguns casos, dificultar o combate à criminalidade.

Direitos individuais fundamentais não surgiram por acaso. Decorreram de luta histórica contra abusos e excessos do poder punitivo estatal, tendo sido estabelecidos justamente para limitá-lo. E limitá-lo não em prol apenas de delinquentes, mas sim de todos os cidadãos, que, um dia, podem se ver injustamente no banco dos réus, quando só então entenderão a importância do respeito ao devido processo legal constitucional e às regras que edificam o Estado Democrático de Direito.

Nesse ponto, salutar rememorar as palavras proferidas pelo Ministro Nefi Cordeiro

por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 509.030-RJ: "Juiz não enfrenta crimes, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação.... O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e, somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. Juiz não é símbolo de combate à criminalidade, é definidor da culpa provada, sem receios de criminosos, sem admitir pressões por punições imediatas".

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu CARLOS ROBERTO JESUS ZOCA, com a devida qualificação nos autos, da imputação do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, V, Código de Processo Penal.

Se for o caso, EXPEÇA-SE certidão para remuneração do Defensor dativo, conforme tabela do convênio DPE/OAB.

Expeça-se, se o caso, alvará de soltura clausulado.

Proceda a Serventia à desvinculação destes autos do meu nome, pois eventuais novas decisões, se necessárias, serão proferidas pelo(a) Magistrado(a) responsável pela Unidade Judicial à época, estando eu vinculado a este feito apenas e tão somente para fins de prolação da sentença, encerrando-se aqui minha atuação.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Intimem-se as partes observando-se a prerrogativa de intimação pessoal do réu que estiver preso (art. 392, I, CPP).

Cumpra-se.

Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Amparo, 28 de abril de 2022.

ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA